

付，应以犯罪未遂定罪处罚；二是代持财物的，既遂。该观点的说理较之未遂要更为复杂。有强调约定财物代持，并已经利用职权谋取利益的；有强调财物代持是双方约定的结果，并时常对账，对财物具有掌控力的；有强调财物被关联人占有的等。由此，受贿罪的争议焦点在犯罪形态，而犯罪形态的争议焦点则在代持型受贿罪的个案犯罪形态认定。除认为代持财物未给付的构成犯罪未遂的外，其他对此类型犯罪的形态判断，均需强调一定的裁判理由。笔者认为，依据控制说的标准对行受贿犯罪的犯罪形态进行确认，能够为该类案件的裁判提供判断方向和说理路径。

代持型受贿作为受贿罪的一种隐蔽的表现形式，认定其犯罪形态的标准与一般受贿罪犯罪形态的认定标准是一致的，均应采取控制说，即以财物是否被受贿人实际控制为标准。实践中，对财物是否被受贿人实际控制的认定依个案情况而不同，需要具体案情具体分析，但总体裁判的路径是通过综合证据链条形成的案件事实判断受贿人对涉案财物的控制力强弱程度，并最终依据受贿人对涉案财物控制力的强弱判定其犯罪形态。一般而言，代持型受贿的代持人分

①储槐植：《储槐植文选》，北京大学出版社2022年版，第448页。

为两种：一种系行贿人代持；另一种系关系人代持。在关系人代持中又可以进一步细分为行贿人指定的关系人代持、受贿人指定的关系人代持。依据代持人的不同，受贿人对收受财物的掌控力是不同的，一般认为，掌控力由弱到强的排列次序为行贿人代持、行贿人指定关系人代持、受贿人指定关系人代持。据此对代持型受贿犯罪的犯罪形态影响由未遂到既遂逐步增强。在此，需着重明确对代持型受贿罪犯罪形态的判断是一个综合判断的过程，打破了一一对应的传统证据模型，不能认为由行贿人代持便是未遂，由指定的关系人代持就是既遂。以本案为例，涉及由行贿人代持的房产、股权、货币(分红款)的犯罪形态以及犯罪金额认定问题，又有受贿人指定关系人行使部分权利对收受房产的间接掌控力判断问题。最终生效裁判依据控制说针对涉案的房产、股权、货币形成了如下裁判思路。

三、代持型受贿罪的裁判路径

(一)关于代持房产型受贿的犯罪形态及金额认定

本案受贿人收受行贿人所送房产一套。该房产系行贿人以其公司名义购买，并根据受贿人要求安排人员对房屋楼顶加建阳光房，安排行贿人将门禁卡交给受贿人的关联人，为掩人耳目，授意行贿人及其家人入住该房屋。有观点认为，房屋系典型的不动产，不动产登记是物权归属的根据，涉案房屋一直登记在李某某公司名下，且徐某某未实际入住，应认定未遂。还有观点认为，刑法上的非法占有的实现不需要以变更登记为前提，因为刑法中非法占有不可能成为合法占有，只要行受贿双方明确了行受贿的意思表示，受贿方实际控制了财物，就应当认定为受贿罪既遂。以房屋为对象的受贿犯罪，受贿方实际控制、使用、占有了房屋就是典型的犯罪既遂。受贿人出于逃避侦查的考虑，不进行房屋权属变更登记或不实际使用房屋，但获取了房屋的钥匙、门禁卡、对房屋进行改造、装修、指定第三人入住、将房屋过户到第三人名下、将房屋出租并收取租金等情形，均可作为实际控制、占有房屋的判断标准，可认定犯罪既遂。本案生效裁判采纳了后一种观点。本案中，行贿人虽未将房屋的门禁卡交付或将门锁密码告知受贿人，但受贿人一直在积极地实施收受房屋并进行支配和处置的

行为。首先，受贿人授意行贿人在屋顶加装阳光房；安排行贿人将门禁卡交给受贿人的关联人；为了逃避调查而多次要求行贿人入住，但却反对行贿人将房屋用于公司办公。上述行为足以体现受贿人控制、支配房产的意愿和具体行为。其次，尽管受贿人没有实际使用该房屋，但不影响其能够通过其关联人对该房屋控制和使用；同时，行贿人安排他人负责管理房屋，受贿人知晓并认可。综上，能够认定受贿人对该房产有足够的控制力，应属受贿既遂。

另外，对收受房产型受贿的犯罪形态和价值认定，则因全款购房或按揭贷款购房而存在区别，本案系全款购房故在犯罪既遂的基础上以购房金额作为犯罪金额。在行贿人以按揭贷款购房行贿案件中，认定其犯罪形态与受贿金额，则因行贿人以按揭贷款方式购房而需具体分析，以法院审理的李某某受贿案的裁判思路，对房产已经认定受贿既遂，对于受贿金额的认定，则已经由行贿人支付的部分是犯罪既遂，未支付的部分应属于犯罪未遂。

（二）关于代持股权型受贿的犯罪形态及价值认定

本案中，被告人徐某某与李某某达成行受贿合意，收受李某某所送股权，该股权系具有价值的实质性财物，而非仅仅收受股份对应的分红款，故应当以收受股权价值认定其受贿金额，但不能因此得出犯罪既遂的结论，还要审查受贿人是否已获取或实际控制该股权。受贿人为请托人谋利的行为与受贿人收受贿赂的行为是两个行为，需要分别予以确认，本案中行贿人赠予受贿人股权的行贿行为虽有多种表现形式，但受贿人事实上并未实际对该股权具有足够的掌控力。行贿人对股权和分红款的处置行为均是事前处置，虽受贿人事后予以认可，但仍可见受贿人对该股权和分红款的掌控力弱于行贿人，据此认定该笔受贿犯罪未遂，是恰当的。

另外，对股权价值的认定。行贿公司的营业范围主要为私募股权投资基金管理业务以及其他资产管理、顾问业务，从运行管理相对规范的上市公司选取经营业务与之类似的公司作为可比公司，为其企业价值评估提供关键数据，并运用市场法进行评估具有合理性。并且，采用市场法得出的

264 中国法院2025年度案例·刑事案例四

结论，与李某某同期向他人出卖股权所获得收益最为相近。因此，虽对股权的认定有市场法、收

益法和成本法三种，但还需要结合其他事实综合选择、认定。行贿公司作为轻资产公司，缺少固定资产，本身的团队和个人业务能力才是公司的赢利保障，对此一般不会用成本法(注册资本之类的)对其股价进行评估。

(三)代持货币(分红款)型受贿的犯罪形态及金额认定

其裁判路径与前述代持股权型受贿一致。本案中，李某某对分红款的处置行为是事前处置，虽徐某某事后予以认可，但可见徐某某对该分红款的掌控力弱于李某某，据此认定徐某某该笔受贿犯罪未遂，是恰当的。

另外，徐某某利用职务之便，为李某某等人已提供实际帮助，对受贿款物的金额、处理方式双方已达成合意，已经着手实施犯罪，由于徐某某被查处等原因受贿款物未实际交付，故应认定其犯罪未遂。

总之，判断代持型受贿罪的犯罪形态，标准仍是受贿人是否对“收受财物”具有足够的控制力。在认定受贿人对代持财物有足够控制力的情况下，可以认定犯罪既遂，但对按揭购房等未全款购房的情况，可以对犯罪金额的认定区分为部分既遂、部分未遂。在判断受贿人对代持财物是否有足够控制力时，要综合全案证据予以判断，并不要求受贿人实际将房产过户、入住、安排近亲属入住，只需受贿人对该财物通过各种方式实现事实上的占有、使用、收益、处分的足够控制力即可。在裁判文书说理时，需重点表述受贿人采取了多种方式实际上对该财物具有控制力，且该控制力应排除全部由行贿人掌控的情况，有时针对个案还需排除受贿人掌控力弱于行贿人的情形，综合全案事实方可认定犯罪既遂。

编写人：重庆市第五中级人民法院 张晓威

放贷收息型受贿的认定及数额计算^①

——韩某受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2022)苏02刑初7号刑事判决书

2. 案由：受贿罪

【基本案情】

2012年至2020年，被告人韩某利用担任J市副市长、市公安局局长、市政协副主席等职务便利，为相关单位和个人在案件处理、企业经营、职务提拔、岗位调整等方面提供帮助，先后收受他人给予的财物共计折合人民币873.6万余元(以下未标明币种均为人民币)。其中，一笔事实如下：2013年8月，陈某甲的儿子陈某乙、A公司董事会秘书高某某因涉嫌犯操纵证券市场罪被湖北省T市公安局立案侦查。同年9月，该局对陈某乙、高某某上网追逃并冻结陈某乙银行账户资金4000万元。同年11月23日，高某某被江苏省Z市公安局抓获，根据规定应将其移交湖北省T市公安局处理。经陈某甲请托，被告人韩某先与Z市公安局协调将高某某移交J市公安局，J市公安局再出面帮助陈某甲与T市公安局协调，最终撤销上述案件并对陈某乙的银行账户解封。2013年至2018年，陈某甲实际控制的A公司系当地知名上市公司，经营状况良好，公司账户流动资金常年保持在2亿元左右，银行给该公司的贷款授信总额度在5亿

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-03-1-404-006。

元左右，年利率为5%。2013年12月，陈某甲为感谢韩某在案件处理中提供的帮助，双方商定由韩某以其妻弟陈某丙的名义与陈某甲参股的小额贷款公司B公司签订《投资借贷协议》，约定出借金额500万元，年化利率不低于20%，但未约定借款期限。该500万元未按协议约定进入B公司账户，而是被陈某甲用于炒股及个人生活开销。2015年至2017年每年四五月间，韩某先后3次收受陈某甲以B公司上一年度“分红款”名义所送的各100万元，共计300万元。该300万元均来自陈某甲自有资金，与B公司经营情况无关，且2014年至2018年B公司总经营业绩亏损，也从未进行过分红。2018年6月，陈某甲及A公司、B公司因陷入债务危机导致资金链断裂，陈某甲仍四处筹集资金将500万元本金还给韩某，并承诺待经营好转将支付2017年度“分红款”100万元，但因客观原因尚未支付即案发。韩某实际收受陈某甲贿赂的现金400万元（其中100万元未遂）。

【案件焦点】

韩某利用职务之便，为请托人谋取利益，后通过“放贷收息”形式收受请托人400万元（其中100万元未遂）“投资收益”是否构成受贿罪。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：被告人韩某的行为属于放贷收息型受贿，韩某利用职务之便为陈某甲谋取了不正当利益，陈某甲为感谢韩某的帮助，以支付利息名义向韩某进行利益输送，双方之间已经形成了明确的权钱交易关系，应当以受贿论。韩某与陈某甲之间系虚假民间借贷关系。陈某甲及A公司并无实际资金需求，而是以借贷为名对韩某进行利益输送；借贷协议及资金走向有违交易习惯，未约定借款期限，出资未按协议约定进入B公司账户，而是被陈某甲用于炒股及个人生活开销；韩某所得的“高额利息”均来自陈某甲自有资金，与B公司经营情况无关；韩某收到的所谓“利息”数额特别巨大。

被告人韩某收受的400万元“利息”均应认定为受贿数额，因为韩某与陈

某甲之间的借贷协议是意思表示虚假的民事法律行为，双方间也非平等的民事主体关系，该借款利息不受民事法律保护，其受贿数额即非法获取的全部“借款利息”。

江苏省无锡市中级人民法院作出判决：

被告人韩某犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案系国家机关工作人员利用职务之便，为请托人谋取利益，后通过放贷收息形式收受请托人财物的放贷收息型受贿的典型案例。放贷收息型受贿往往披着民事经济行为外衣，通过更为隐蔽、特殊的方式达到权钱交易目的的违法行为。本案的争议焦点为被告人韩某“放贷收息”行为性质和犯罪数额的认定。

一、国家机关工作人员放贷收息型受贿行为的认定

关于韩某“放贷收息”行为性质的认定存在争议。第一种观点认为，该行为违反《中国共产党纪律处分条例》第九十九条第二款的规定^①，属于违反廉洁纪律。第二种观点认为，该行为属于放贷收息型受贿，韩某利用职务之便为他人谋取不正当利益，请托人以支付利息名义向韩某进行利益输送，应以受贿罪论处。笔者同意第二种观点。司法实务中，对国家工作人员违规放贷行为是否构成受贿罪的认定，应重点审查以下方面。

1. 借贷双方是否存在权钱交易关系。受贿罪的本质是权钱交易，即国家机关工作人员利用职务之便为请托人谋取利益。借贷双方存在权钱交易行为是判断受贿罪构成与否的前提条件。实践中，放贷收息型受贿存在两种情形：一是借贷双方存在明确的请托事项，国家工作人员利用职务之便为请托人谋取利益；二是借贷双方虽无明确请托事项，但存在上下级、制约或管理服务关系的，也能

^①《中国共产党纪律处分条例》第九十九条第二款规定，通过民间借贷等金融活动获取大额回报，可能影响公正执行公务的，依照前款规定处理。

够认定系利用职务之便为他人谋取利益，其中谋取利益不要求利益已经实现，有承诺的意思表示即可。

2. 借贷双方是否存在真实借贷关系。主要从以下方面审查判断：一是借款人有无真实资金需求。在正常民间借贷中，借款人多基于生产经营、大额消费支出等需要向金融机构或亲朋好友拆借资金用于周转。如果借款人本人或其经营的企业本身资金雄厚，或者能从金融机构以较低的利率进行融资，依然主动或被动向国家工作人员借贷，则可认定借款人没有真实的资金需求。二是借贷资金的实际用途。正常民间借贷的资金一般用于借款人生活消费或其企业的生产经营，但如果资金实际用途与借款人事先承诺完全不符，亦能侧面反映出其无真实资金需求。三是借贷协议是否规范。民间借贷双方一般会以书面协议约定借款数额、利息和借款期限等基本内容。如果国家工作人员与借款人非亲非故，并假借他人名义与借款人签订合同，或仅仅只有口头约定就出借大额资金，可以认定借贷行为存在异常。四是出借人是否承担放贷风险。放贷收息型受贿中，贿赂双方的借贷地位是不平等的，请托人因有求于国家工作人员为己谋利而在借贷关系中处于被动地位，国家工作人员在放贷关系中无须承担放贷资金及利息无法收回的风险。

3. 审查借款利息的高低。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义，虽然实际出资，但获取的“收益”明显高于出资应得收益的，以受贿论处。关于该条中的“委托理财收益”的多寡，可根据民间借贷利率的高低进行判断。如果借贷双方约定的利率超过一年期贷款市场报价利率(LPR)的四倍，①一般可以认定为高额利息。实践中，由于地区经济发展不均衡，除参照LPR报价外，还应结合地区经济发展实际和民营经济活跃程度进行判断。

①《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条第一款规定，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。

二、放贷收息型受贿犯罪数额的认定

对于如何确定被告人韩某的受贿数额亦存在两种观点：第一种观点认为，受贿数额应当是收取的全部利息；第二种观点认为，受贿数额应当减去合理利息收益，对于合理利息又有按银行同期贷款利率、同期借款利率，以及按LPR的四倍等计算的观点。笔者赞同第一种观点，主要理由是。

1. 放贷收息型受贿中的借贷双方并非平等的民事主体。民间借贷利息相关规定适用的是平等民事主体间的借贷行为，即双方主体地位平等，不存在从属性和依赖性。如果借贷双方间存在领导、管理、监督、制约或请托关系，就不再是平等主体之间的民事法律关系，所产生的“利息”则是权钱交易的筹码，应全部认定为受贿数额。

2. 放贷收息型受贿中的借贷双方存在行受贿的意思表示。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。借贷双方如利用“借贷”之名，行受贿之实，且双方主观上均对此明知，即借贷合同无效，合同所产生的利息当然不再受到民事法律保护。

综合上述分析，本案中，韩某利用职务之便为陈某甲谋取不正当利益，陈某甲及其公司无实际资金需求，仍与韩某的特定关系人签订《投资借贷协议》，约定借款金额500万元，年化利率不低于20%，且所涉500万元“出资”未进入公司账户，而用于陈某甲个人生活消费。陈某甲以借贷为名向韩某输送利益，三年间以自有资金支付300万元“利息”。2018年，陈某甲及其公司资金链断裂，仍四处筹集资金向韩某归还全部本金，并承诺待经营好转后支付当年的100万元利息，该100万元系受贿未遂。因此，可以认定韩某利用职务之便，为请托人谋取利益，后通过“放贷收息”形式收受请托人财物，应当以受贿罪论处，案涉400万元“利息”均应认定为受贿数额。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 范凯 宋婉龄

隐形受贿罪、行贿罪的认定

——冷某受贿、违法发放贷款、行贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省恩施州中级人民法院(2023)鄂28刑初17号刑事判决书

2. 案由：受贿罪、违法发放贷款罪、行贿罪

【基本案情】

2013年至2021年，被告人冷某利用其担任某银行某支行行长的职务便利，为他人贷款申请、贷款审批、贷款发放以及贷后管理等方面谋取利益，非法收受、索取他人财物共计折合人民币3000余万元；在担任某银行某支行行长期间，违反《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》中严格审查和审慎经营的规定，给某银行某支行授信客户发放贷款，数额特别巨大，给金融机构造成特别重大经济损失；在担任某银行某支行行长期间，为感谢某银行原党委书记、董事长陈某某在安排冷某担任某银行某支行行长等事项上的帮助，先后3次送给陈某某财物共计37余万元。

冷某于2022年7月8日被监察机关留置。冷某到案后如实供述犯罪事实，除主动交代组织已经掌握的其受贿395万余元和行贿犯罪事实外，还主动交代组织尚未掌握的其收受肖某等10人贿赂2850余万元的问题，主动供述的受贿数额占认定事实的大部分。冷某还主动交代组织尚未掌握的违法发放贷款涉嫌犯罪的主要事实。另外，冷某到案后积极举报了十余人涉嫌犯罪的线索，其中二人因涉嫌职务犯罪已被监察机关立案调查并采取留置措施。

【案件焦点】

1. 冷某与工业公司法定代表人吴某某之间的借贷关系能否认定为受贿以及受贿数额如何认定(涉及其中一笔受贿事实);2. 关于某运输公司行贿的25.65万元(保时捷的车辆市场价与实际购车价的差价),是认定冷某构成受贿罪的同时,又认定冷某给实际购车人陈某某行贿罪成立,还是认定冷某与陈某某构成共同受贿犯罪的问题。

【法院裁判要旨】

湖北省恩施州中级人民法院经审理认为:被告人冷某身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受他人财物共计3251.206767万元,构成受贿罪,且数额特别巨大;违反国家规定发放贷款10.5亿元,构成违法发放贷款罪,且数额特别巨大,并造成特别重大经济损失;为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物37.9463万元,情节严重,构成行贿罪。冷某所犯三罪均应依法追究其刑事责任,并数罪并罚。冷某受贿行为持续时间长,多次受贿,其中两人系索贿,应予从重处罚。冷某到案后能够如实供述案件事实,依法可以从轻处罚,且除如实交代组织已经掌握的其受贿395万余元和行贿犯罪事实外,还主动交代组织尚未掌握的其收受肖某等10人贿赂2850余万元的问题,主动供述的受贿数额占认定事实的大部分,可对其所犯受贿罪在量刑时充分考虑;冷某能够认罪认罚,约三分之一受贿赃款已查扣到案,根据其坦白和没有全额退缴受贿赃款,但个人再无退赃能力的情况,可认定其认罪态度较好,量刑时予以综合考虑。冷某到案后还主动交代组织尚未掌握的违法发放贷款涉嫌犯罪的主要事实,以自首论,依法可对该罪予以从轻或者减轻处罚,但其犯罪数额特别巨大,并造成特别重大经济损失,酌情考虑该罪的量刑幅度。冷某能够如实供述行贿犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。另,冷某到案后积极举报了十余人涉嫌犯罪的线索,其中二人因涉嫌职务犯罪已被监察机关立案调查并采取留置措施,一人涉案贿赂金额达1700余万元,应认定为立功,依法可以从轻或者减轻处罚。据此,判决如下:

一、被告人冷某犯受贿罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金150万元;

犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金170万元；

二、对被告人冷某的违法所得予以追缴；对扣押、查封在案的涉案财产，依法予以没收，上缴国库；不足部分，继续追缴。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的焦点主要有两个：一是冷某与工业公司法定代表人吴某某之间的借贷关系能否认定为受贿，受贿数额如何认定；二是某运输公司行贿的25.65万元(保时捷的车辆市场价与实际购车价的差价),是分别认定冷某构成受贿罪、行贿罪，还是认定冷某与陈某某构成共同受贿犯罪的问题。

一、冷某收受的吴某某利息款370余万元应认定为贿赂款

吴某某在案发时段存在资金需求，并主动向冷某提出借款要求，冷某介绍前妻赵某为吴某某借款，实际上还是由冷某代赵某签的合同。冷某不直接借款给吴某某主要原因是碍于其行长身份按照规定不能给客户借款，而冷某愿意借款也是基于其行长身份，既可以对借款风险进行把控，又可以获得较大利益。冷某与前妻赵某虽于借款前就登记离婚，但二人的婚生子跟随赵某生活，冷某与赵某仍存在共同利益。冷某与吴某某在借款之前就存在利益关系，吴某某向冷某借款，一方面确有资金需求，另一方面是感谢冷某之前利用职务上的便利为吴某某谋取利益，并期望冷某继续为其谋取利益。冷某借前妻之名为吴某某提供借款并收取利息的行为，本质上还是权钱交易，应当认定为受贿行为。

对于如何认定该起受贿的金额，现行法律暂没有明确的规定。根据判例，高息借贷型受贿犯罪在具有贷款需求的情况下，出借人收取明显高于其他不特定贷款对象的利息差额，应当认定为受贿数额。在无法确定上述差额的情况下，以借款合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍对比认定。在该起事实中，约定月息为2%。在案证据证明吴某某所在公司向其

他单位借款利息存在月息 3%的情况，故其约定利息未高于其他类似借款利息，不能以出借人收取明显高

于其他不特定贷款对象的利息差额的方式计算受贿款。而在无法确定上述差额的情况下,可以考虑借款合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍对比认定。

二、关于某运输公司行贿的25.65万元,应认定冷某分别构成受贿罪、行贿罪

从主观方面看,冷某通过职务便利向某运输公司提出低价购车要求,主观上有通过低价购车收受贿赂的故意。陈某某是冷某的上级领导,之前就利用职权为冷某提供过便利,冷某为其低价购车有向陈某某行贿的故意。从客观行为看,冷某有向销售汽车的车企表达给其领导购车的意图,向陈某某转达车企关于车价、车型的意见,垫付购置税和保险费用等行为,然后达到为陈某某低价购车的目的。陈某某则实施了向冷某提出犯意,后收受好处的行为。故,冷某帮助陈某某以低于市场价格25.65万元购车的行为,根据主客观相一致原则,应认定冷某分别构成受贿罪和行贿罪。冷某收受某运输公司行贿的25.65万元既具有受贿故意,又存在行贿故意,虽然出现在同一个事实发生过程中,但二者并不具有牵连和相互吸收关系,且冷某行为积极,罔顾法律规定,主观恶性较大,以一罪处断不足以评判其该犯罪行为。因此,应根据主客观相一致原则,认定其分别构成受贿罪和行贿罪。

实践中,犯罪分子打着借贷、投资等幌子向管理服务对象敛财,管理服务对象往往以高额的回扣为成本,让领导干部利用职权为其提供便利。在审理这类案件时,要揭开犯罪行为“市场化”“民事化”“合法化”的面纱,坚持主客观相一致原则,善于根据案件客观事实,借助常识、常情、常理和逻辑法则、经验规则,对行为人真实的主观意图进行分析和证明,将隐蔽化、模糊化的受贿犯罪故意挖掘并清晰展现出来。

编写人:湖北省恩施州中级人民法院 姜亚运

委托行贿人代为保管未实际交付贿赂款的犯罪形态认定^①

—— 于某某受贿、徇私舞弊假释案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省徐州市中级人民法院(2022)苏03刑初56号刑事判决书

2. 案由：受贿罪、徇私舞弊假释罪

【基本案情】

1998年至2016年，被告人于某某先后利用担任某监狱管理局党委委员、副局长、党委书记、局长职务便利，为某茶厂法定代表人于某乙等39家单位或个人在企业经营、刑罚执行、干部选拔任用等方面提供帮助，本人或通过他人收受现金、购物卡、书画等财物，共计价值人民币2180.905万元，用于投资理财、家庭支出等。其中，收受其弟于某乙贿赂款中有一笔500万元至案发一直由于某乙代为保管理财，于某某未实际占有取得。

(其他受贿事实及徇私舞弊假释事实略)。

【案件焦点】

行受贿合意达成后，在行贿人未实际交付的情况下，受贿人委托行贿人代为保管贿赂款，如何认定既未遂。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：被告人于某某身为国家机关工作

^①入库案例，参见人民法院案例库2023-03-1-404-002。

人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；被告人于某某身为司法工作人员，徇私舞弊，对不符合假释条件的罪犯予以假释，其行为已构成徇私舞弊假释罪。被告人于某某在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人于某某部分受贿事实中为他人谋取职务提拔、调整，依法应当从严惩处；被告人另有坦白、认罪认罚、小部分受贿未遂、退缴全部违法所得等从轻或从宽处罚情节。据此，判决如下：

一、被告人于某某犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元；犯徇私舞弊假释罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币200万元；

二、被告人于某某退缴的违法所得及扣押在案的涉案赃款赃物予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案主要争议焦点在于被告人于某某收受其弟于某乙贿赂款500万元既未遂问题。于某某收受于某乙贿赂款共计696万元，其中一笔500万元在双方明确达成行受贿合意情况下，由于网络举报不断，被告人于某某担心案发，授意其弟于某乙代为保管并进行投资理财，两人约定于某某可随时随取，至案发于某某始终未实际使用该500万元，对该500万元既未遂的问题存在不同意见。

根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，犯罪未得逞是犯罪未遂与犯罪既遂相区别的主要标志。按照犯罪构成理论，犯罪未得逞包括结果犯之犯罪未完成、行为犯之犯罪未完成、危险犯之犯罪未完成。受贿罪的犯罪构成不但有对危害行为的规定，而且也暗含着对结果的要求，即得到财物。正因如此，受贿罪既遂与未遂的区分关键就在于结果的发生，即以是否收受他人财物为标准。然而，司法实践中收受他人财物的表现形式复杂多样，究竟如何具体认定，刑法理论界存在着不同的观点，主要有转移说、藏匿说、控制说、失控

说、失控+控制说等几种。司法实务中，公认的是“控制+失控”说，即应以财物是否脱离所有人的控制，并实际置于行为人的控制为标准。

一、财物已经脱离行贿人的控制，并已经实际置于受贿人控制之下，构成受贿罪的既遂

行受贿属于对合犯罪，只有在受贿人得到控制(包括指定的第三人控制)、行贿人失去控制的情况下才能认定为既遂。例如，司法实践中有很多案例系行贿人已经将贿赂款交付给受贿人，受贿人又委托行贿人代为保管，或是行贿人按照受贿人要求，将贿赂款交付给指定的第三人，前者可以视为受贿人在受贿既遂后的赃款处置，后者实质上已经脱离行贿人的控制且被受贿人指定的第三人控制，符合“控制+失控”说理论，均应依法认定为既遂。

本案中，虽然于某乙是于某某的亲弟弟，于某某对于某乙有着极强的控制力，于某乙对财物的保管、打理一直遵从于某某的要求，且于某乙的生意经营依赖于某某开展，对于某某一直有期待利益，但是不能基于此就认定于某某通过对于某乙的影响力实现了对财物的支配与控制。另有既遂观点认为，于某某与于某乙达成了代持的合意，于某某未实际收到贿赂款系基于“代为保管”的合意导致，而非行贿人不想给、无法给等受贿方意志以外的原因导致，且该500万元已经特定化，虽由于某乙短期借用，但借用时间较短，借用后立即还款，恰恰体现了于某乙主观上认为500万元是于某某所有、应当持续理财的。上述观点虽然说明了行受贿双方之间确实存在特殊的关系、行贿人确实想将财物送给受贿人，但都不符合“财物已脱离行贿人控制，并实际置于受贿人控制”的基本标准，不能因此认定本案系犯罪既遂。

二、贿赂款由行贿人保管尚未实际交付给受贿人，不能认定受贿人已经实际控制，亦不能认定行贿人已经失去控制，后因案发而未实际获得应构成受贿罪的未遂

如果贿赂款还在行贿人手里，从来没有发生实质转移，即便行贿人经济实力再强、行受贿双方关系再好，行贿人是多么地讲信誉，行贿人相对于受贿人而言始终还是实际控制者，在此情形下不宜认定为犯罪既遂。

本案中，双方就贿赂金额达成一致后，在未实际交付的情况下由行贿人代为保管，直至八年后案发时被告人仍未实际占有支取，应属于犯罪未遂：(1)涉案500万元始终未实际交付。从2014年年初至2021年年底案发，近八年时间里，该500万元一直由行贿人于某乙实际占有和控制，未实际交付给被告人于某某。

(2)行贿人长期实际占有该500万元，并实际获息200~300万元。系列客观证据证实，近八年时间里行贿人于某乙取出、存入、部分使用该500万元，且大多情况是与其他资金混同存放、甚至转移至案外第三人卡上，并获取了200~300万元的利息，具体过程并未告知被告人。(3)被告人于某某家中有使用贿赂款的紧急必要却从未动用，近八年时间里被告人多次因家中急需资金向行贿人借钱，后均已归还，而对上述500万元仅在2021年提出过一次使用，还因所购买的理财产品没有到期而未实际使用。因此，本案的情形不符合“失控+控制”说的标准，不应认定为受贿既遂。

三、严格按照“失控+控制”说有利于准确区分受贿既未遂

有观点认为，如果严格按照“失控+控制”说，会使很多犯罪分子有机可乘，在受贿时故意不实际交付而是放在行贿人处，随用随取，如果案发，就以自己没有实际控制、行贿人没有失去控制为由逃脱法律责任，所以应当根据行贿人与受贿人之间的关系、行贿人的经济实力以及行贿人的诚信等方面综合判断。

这种观点局限于分析受贿人的控制力，不符合“控制+失控”说的通说观点。首先，在没有实际交付贿赂款的情况下，控制力的大小应当在行贿人和受贿人之间进行考察和比较。在贿赂款没有实际交付而是由行贿人掌握的情况下，无论受贿人的控制力有多强，只要行贿人还是一个独立自主的主体，受贿人对贿赂款的控制力始终小于行贿人的控制力，这种认定是符合常识、常情、常理的。其次，只要贿赂款没有实际交付，未来出现行贿人反悔或经营不善破产等导致不能正常支付的可能性都会存在，所以将受贿罪既未遂的认定标准设定为行贿人信用、经济实力等可变而不可控的要素，将导致司法实践认定不统一，极易产生混乱，所以这种观点是不可取的。

综上，受贿罪中收受他人财物既未遂之认定应坚持“失控+控制”说，凡

是财物已经脱离行贿人的控制，并已经实际置于受贿人控制之下，即为受贿罪的既遂，否则为未遂。在没有实际交付的情况下，不能认定受贿人已经实际控制，更不能认定行贿人已经失去控制，故本案中应认定被告人于某某收受其弟于某乙的500万元为受贿未遂。

编写人：江苏省徐州市中级人民法院 刘明伟 李通达

“转圈粮”行为的司法规制

——黄某某受贿、贪污、滥用职权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省南城县人民法院(2022)赣1021刑初23号刑事判决书

2. 案由：受贿罪、贪污罪、滥用职权罪

【基本案情】

某粮食收储公司(以下简称收储公司)主要从事定购粮、议购粮、中央和地方储备粮的收购、储存、调拨业务。2015年至2021年，黄某某在担任收储公司经理期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受曹某某、刘某等钱财共计10.96万元。2016年至2019年，黄某某利用职务上的便利，采用虚开发票的方式非法占有公共财产7.64万元。

为了完成收储公司2013年至2015年省级、2014年县级储备粮总计9935.1吨的轮入任务，2015年1月5日上午，黄某某召集县收储公司副经理刘某某、李某甲、党支部书记李某乙、计统部主任邓某某、结算部主任曾某某开会研究省级、县级储备粮轮入事宜。会上，黄某某提出通过找农甲公司回购2013年

“托市粮”，但粮食并不实际出库的方式，充当2014年新粮入库进行省级、县级储备粮收购储备（俗称“转圈粮”），参会人员均无异议。当天会议后，收储公司与农甲公司签订了一份以2440元/吨的价格向其收购9917吨粮食的意向合同。

网拍当日，农甲公司发现收储公司2013年入库的“托市粮”挂网拍卖价格远高于市场价，便只竞拍了4409吨。剩下的5525吨“托市粮”分别被农乙公司、农丙公司、农丁公司拍得。之后，在黄某某的周旋及农甲公司协助之下，这四家公司将各自拍得的“托市粮”总计9934吨转卖给了收储公司，上述粮食均在收储公司下属粮管所粮仓内，未实际出入库。后收储公司在粮食原仓未动的情况下，将4903吨的购粮款转给农甲公司，并通过制作虚假入库码单，在账面上完成了2015年省级储备粮轮入任务。

由于收储公司的2014年县级储备粮的收粮款是向银行贷款所得，按照相关规定，收粮价必须按2015年国家规定的粮食最低收购保护价2700元/吨执行。而收储公司之前与农甲公司签订的合同价为2440元/吨，通过这份合同无法进行贷款。于是收储公司又与农戊公司签订一份购粮合同，由收储公司先以2700元/吨的价格向农戊公司支付收粮款，并制作虚假的入库码单，在账面上完成了县级储备粮的轮入任务。之后由农戊公司以2400元/吨的价格支付实际回购的收粮款给农甲公司，剩余的差价135.16万元，由农戊公司通过个人账户转回给收储公司公账中。因转圈的2013年的托市粮实际只有9914吨，为了完成省、县级储备粮合计9935.1吨的任务，黄某某安排邓某某虚开入库凭证，将差额的20余吨粮虚假轮入收储公司用于储存省级、县级储备粮的相关仓库中。

收储公司通过以陈顶新、虚假轮换的方式，完成2013年至2015年省级、2014年县级储备粮轮换后，获得省级和县级储备粮轮换补贴及保管费合计650.05万元的国家财政资金。该笔资金全部进入该公司财务账，未单独设立专户，与公司其他资金合并用于日常经营管理。

【案件焦点】

黄某某实施的“转圈粮”行为是否构成犯罪以及构成何罪。

【法院裁判要旨】

江西省抚州市南城县人民法院经审理认为：被告人黄某某系国有公司经理，属国家工作人员，又系受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。其在公务活动中，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人现金共计10.96万元；利用职务上的便利，非法占有公共财产共计7.64万元。公诉机关指控被告人黄某某犯受贿罪、贪污罪罪名正确，应予认定。关于公诉机关指控被告人黄某某实施了滥用职权行为的事实，法院认为：第一，县收储公司是全民所有制企业，被告人黄某某系县收储公司经理，是由南城县粮食局任命的，属于受国家机关委托在国有公司任职的人员。同时，县收储公司从事的省、县粮食储备、轮换等工作，是由市政府下达抄告单，指令必须完成的工作任务，属履行国家行政管理职能，且储备粮所有权、使用权属政府，储备粮由当地国有粮食企业代收代储。据此，县收储公司实施的储备粮收储、轮换等行为，是受政府委托具有行政管理职权的公务行为。被告人黄某某作为县收储公司的经理，应属受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。故，根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，被告人黄某某符合渎职犯罪的主体身份。第二，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第五条第二款（以下简称《解释》）的规定，以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》分则第九章的规定追究国家机关负有责任的人员的刑事责任。对于具体执行人员，应当在综合认定其行为性质、是否提出反对意见、危害结果大小等情节基础上决定是否追究刑事责任和应当判处的刑罚。采取“转圈粮”方式套取国家补贴，是公司经理黄某某提议并通过会议形式确定，黄某某起组织、策划作用，其行为符合以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，应当追究刑事责任。且根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、

实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。因此，追究被告人黄某某滥用职权刑事责任的法律依据充分。第三，国务院颁布的《粮食流通管理条例》规定储备粮不得以陈顶新，市政府下达的粮食轮换抄告单明确要求要轮入新粮。被告人黄某某在明知有规定轮入的政策性粮食必须为新粮的情况下，仍然安排县收储公司工作人员具体操作“转圈粮”，通过虚购虚销、以陈顶新等手段，采取库存不动、账面转圈，制作虚假出入库码单等方式将2013年托市粮以购新粮的名义完成2015年省级储备粮、县级储备粮的轮入计划，套取国家财政专项资金，其行为违反了粮食流通、轮换的规定及国家专项资金财政管理的相关规定。被告人黄某某作为国家政策性粮食收储公司的经理，本应依法、依规行使权力，却滥用手中的权力，通过“转圈粮”为公司套取国家专项资金，具有刑事违法性。第四，根据《解释》第八条规定，本解释规定的“经济损失”是指渎职犯罪或者与渎职犯罪相关联的犯罪立案时已经实际造成的财产损失。本案中，套取的650余万元国家财政资金至案发时，虽仍在县粮食收储公司的公账上，且已被追缴，但因是通过“转圈粮”这种虚假的轮换行为，致使本不能申报获取的国家专项资金流出，成为公司的自有资金，可由公司自由支配，甚至滥用，导致追赃挽损困难，为国家专用资金带来巨大安全隐患，应认定国家利益遭受损失。重大损失不仅包括实际可量算的财产损失，还应包括公共财产、国家和人民利益其他方面的损失。国家建立储备粮制度，目的是确保国家粮食安全，遇到应急需要时，确保百姓有饭吃。任由“转圈粮”等破坏粮食安全制度行为的泛滥，终将会造成粮食过期变质、仓内无粮、应急时百姓无粮可食等严重后果。故，被告人黄某某实施的以陈顶新、采取虚假手段为公司套取专项财政资金的行为，既侵犯了国家财政专项资金的专属性，又严重破坏了我国粮食流通管理制度，危害了国家粮食流通领域的安全、稳定，具有严重的社会危害性。应认定被告人黄某某实施的滥用职权行为“情节特别严重”。

综上，被告人黄某某系国有公司经理，属国家工作人员，又系受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。其在公务活动中，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人现金共计10.96万元；利用职

务上的便利，非法占有公共财产共计7.64万元；违反国家相关规定，通过“转圈粮”的方式弄虚作假、以陈顶新，进行省级、县级储备粮轮换，累计套取国家财政专项补贴650.05万元，造成国家财政专项资金重大损失，且破坏了我国粮食管理体制，导致国家确保粮食安全的制度形同虚设，危害国家粮食安全，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，符合滥用职权罪的构成要件。

在实施本案犯罪过程中，被告人黄某某在受贿罪、贪污罪中均属数额较大；在滥用职权罪中，属情节特别严重。被告人黄某某在受贿、贪污中具有在提起公诉前，如实供述自己罪行，真诚悔罪，积极退赃，避免、减少损害发生的情节，依法可从轻处罚；在滥用职权罪中，经过单位集体研究，违法所得套取后仍在单位账上，已全部被追缴到位，且具有自首情节，可酌情从轻处罚。

江西省抚州市南城县人民法院于2022年8月31日作出判决：

一、被告人黄某某犯受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20万元；

二、已退缴的违法所得共计668.65万元，由监察机关上缴国库。案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

“转圈粮”行为不仅损害了人民群众的利益，扰乱了粮食市场秩序，还危及国家储粮安全。实践中，对“转圈粮”行为是否构成犯罪以及构成何罪存在较大争议。本案中，黄某某实施的“转圈粮”行为系集体研究，且套取的资金尚在公司账上，案件争议焦点主要集中在两个方面：其一，黄某某实施的“转圈粮”行为是否构成犯罪；其二，若构成犯罪，应构成何罪。

一、“转圈粮”行为入罪的应然分析

行为具有一定的社会危害性，是犯罪最基本的特征。所谓“转圈粮”是指在执行国家政策性粮食收储和储备粮轮换过程中，粮食收储企业通过虚购虚销、以陈顶新、未轮报轮等方式获取不当利益，破坏国家粮食流通秩序，危害粮食

安全的行为。“转圈粮”行为的社会危害性主要表现在：第一，破坏国家行政管理秩序。我国《粮食流通管理条例》《中央储备粮管理条例》等行政管理法规明确规定不得通过以陈顶新、以次充好、低收高转、虚假购销、虚假轮换、违规倒卖等方式，套取粮食价差和财政补贴，骗取信贷资金。对违反相关规定 的行为根据具体情况分别给予行政处罚、违纪处理以及承担刑事责任。“转圈 粮”行为违反了上述规定，侵害了国家行政管理秩序。第二，侵害国家财产权 益。因粮食储备成本由国家财政支付，行为人实施“转圈粮”行为获取巨额价 差，套取保管、轮换费用补贴，造成国家财产损失，严重侵害了国家财产权益。

第三，危害粮食安全和国家安全。国家建立储备粮制度，目的是确保国家粮食 安全，遇到应急需要时，确保百姓有饭吃。“转圈粮”行为把陈粮作为储备粮， 造成粮食过期变质，在非紧急状态下，若流入市场可能引发食品安全问题，影 响人民群众的身体健康；在紧急状态下，如战争、地震、疫情等需要动用储备 粮时，可能无粮可食，无法满足战备、赈灾救灾等突发情况的需要，对国家安 全造成严重影响。故，“转圈粮”行为具有刑事危害性和违法性，应受刑罚 规制。

二、黄某某实施的“转圈粮”行为构成滥用职权罪

根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，国家机关工 作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的， 构成滥用 职权罪。行为人是否属于“国家机关工作人员”以及“致使公共财产 、国家和 人民利益遭受重大损失”是认定本罪的两个重要要件。

(一)行为人符合滥用职权罪的主体要件

根据《中华人民共和国刑法》第九十三条的规定，国有公司、企业、 事业 单位、人民团体中从事公务的人员以国家工作人员论。收储公司系全 民所有制 企业，根据当地储备粮管理相关规定，储备粮属政府所有，储备 粮由当地国有 粮食企业代收代储。收储公司从事的省、县粮食储备、轮换 等工作，是按照政 府指令必须完成的工作任务，系履行国家行政管理职能 。收储公司为完成省级 和县级粮食储备粮轮换计划，实施的储备粮收储、 轮换等行为，属于受政府委

托行使行政管理职权的公务行为。黄某某作为县粮食局任命的收储公司经理，属国家工作人员，又系在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，在受国家机关委托，代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，有渎职行为构成犯罪的，也依照《中华人民共和国刑法》关于渎职罪的规定追究刑事责任。故，黄某某符合滥用职权罪的主体要件。

(二)行为人犯罪行为的损失认定

根据《解释》)第八条的规定，“经济损失”是指渎职犯罪或者与渎职犯罪相关联的犯罪立案时已经实际造成的财产损失……根据《解释》第一条的规定，重大损失既包括实际可量算的有形损失，也包括公共财产、国家和人民利益其他方面的无形损失。黄某某通过“转圈粮”行为套取的650余万元国家财政资金至案发时，虽仍在公司账上，且已被追缴，但“转圈粮”行为实际侵犯了三重法益，不仅使本不符合国家财政补贴条件的国家专项资金流失，成为公司的自有资金，造成国家有形财产的损失，还可能损害人民群众身体健康，破坏国家粮食流通管理秩序，危害国家粮食安全，甚至危及国家安全，造成不可估量的无形损失。故，其造成的损失后果是重大的。

三、黄某某应承担的刑事责任

本案“转圈粮”行为系县收储公司班子成员“集体研究”，是否能追究被告人黄某某个人刑事责任。从渎职犯罪相关司法解释来看，以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》分则第九章的规定追究国家机关负有责任的人员的刑事责任。即使渎职犯罪以“集体研究”的形式实施，国家机关负有责任的人员对此仍应承担刑事责任。根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》的规定，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。“转圈粮”行为具有刑

法规定的社会危害性，虽尚未确定为单位犯罪，但黄某某作为收储公司的经理，为完成粮食轮换任务，提议以“转圈粮”方式套取国家补贴，并通过公司会议形式决定实施，且在实施过程中，通过联系粮食销售商、指示他人虚开入库凭证等方式组织安排“转圈粮”相关事宜。黄某某在本案“转圈粮”行为中起组织、策划作用，该行为符合以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，应当追究其刑事责任。

综上，“转圈粮”行为既造成国有财产的有形损失，还扰乱了国家粮食流通秩序，危害国家粮食安全，造成国家和人民利益的无形损失，具有刑事危害性和违法性，应受刑罚规制。国家机关工作人员在执行国家政策性粮食收储和储备粮轮换过程中，通过虚构虚销、以陈顶新、未轮报轮等手段，实施“转圈粮”行为，套取国家财政补贴，破坏粮食流通管理秩序，危害国家粮食安全，构成滥用职权罪。

编写人：江西省抚州市中级人民法院 魏灵

江西省南城县人民法院 邱娜

行为人具有共同行贿的概括故意构成共同行贿犯罪

——苏某某行贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区北海市中级人民法院(2023)桂05刑终37号刑事裁定书

2. 案由：行贿罪

【基本案情】

2017年7月，被告人苏某某与陈甲、林某(均另案处理)共同商议从事北海“一日游”、北海至防城港至东兴“一日游”的运营生意，从中通过收取车票费、景点购物回扣、购房提成及其他车辆“挂靠费”等方式获取收益。由于公安机关对涉嫌非法传销的“一日游”运营予以打击，为使得运营顺利进行，运营的车辆不被查处或者被扣押的车辆能尽快放行，苏某某与陈甲、林某合谋，由陈甲负责疏通北海市海城区执法部门公职人员的关系，苏某某负责疏通北海市银海区执法部门工作人员的关系，林某负责导游等具体运营工作。2017年7月至2018年3月，苏某某及陈甲、林某用从事“一日游”所获得的部分收益向苏某1、李某等(均另案处理)相关部门工作人员共同行贿人民币308万元。在陈甲退出后，苏某某及林某用从事“一日游”所获得的部分收益共同向陈乙行贿8万元，谋取了不正当利益。经查实，2017年7月至2018年3月，被告人苏某某伙同同案人行贿数额为316万元。

另查明。2021年12月9日，苏某某主动到监察机关投案，如实供述自己的罪行，并主动退出违法所得170万元。

【案件焦点】

1. 苏某某与陈甲是否构成共同行贿犯罪；2. 苏某某行贿犯罪数额应认定为多少。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区北海市海城区人民法院经审理认为：被告人苏某某伙同同案人为谋取不正当利益，多次给予多名国家工作人员以财物，情节特别严重，其行为已构成行贿罪。苏某某虽对陈甲行贿的具体对象、数额等情况不清楚，但在意志认知层面，被告人苏某某对陈甲的行贿行为持放任态度，也即无论陈甲行贿谁、行贿多少，只要保证其经营的“一日游”生意顺利运营并获取非法利益，均不超出被告人苏某某的认知范围。苏某某主观上具有与陈甲、林某等人共同行贿的故意，客观上伙同陈甲、林某为谋取不正当利益实施了行贿行为，

被告人苏某某与陈甲、林某构成共同犯罪。被告人苏某某伙同同案人共同行贿的数额为316万元。据此，以行贿罪判处被告人苏某某有期徒刑六年，并处罚金人民币70万元，同时将被告人苏某某退出的违法所得人民币170万元予以没收，上缴国库。

宣判后，苏某某不服一审判决，提出上诉。

广西壮族自治区北海市中级人民法院经审理认为：苏某某与陈甲等人共谋合伙经营“一日游”运输生意事宜，为牟取非法利益而多次贿赂国家机关工作人员共计316万元，各自分工负责，相互密切配合，且利益共享。虽然苏某某对陈甲行贿国家机关工作人员的姓名、数额等具体情况存在不明之处，但陈甲实施的行贿行为并未超出苏某某与陈甲事前商谋为了保证“一日游”运输生意得以顺利运营、赚取非法利益而向国家机关工作人员行贿的概括性犯意，苏某某对陈甲为维护共同利益而行贿持放任、支持的态度，对苏某某应以行贿罪共犯论处。原判认定苏某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于苏某某与陈甲是否构成共同行贿犯罪以及犯罪数额应认定为多少。

一、苏某某与陈甲构成共同行贿犯罪

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，共同故意是认定共同犯罪的关键所在，即行为人之间具有犯意的联络。行为人需要对共同犯罪的事宜有基本认知和意思联络，但这并不意味着各行为人需要对共同犯罪的所有、具体事宜均知晓，达到概括故意的程度即可。概括故意是行为人对于认识的具体内容并不明确，但明知自己的行为会发生危害社会的结果，而希望或者放任这种结果发生的心理态度。行为人具有共同行贿的概括故意，即使对同案人行贿的对象、金

额等具体细节不明确，只要同案人的行为未超出其事前共谋行贿的概括性犯意，仍构成共同行贿犯罪。

具体到本案中，苏某某与陈甲等人共谋合伙经营“一日游”运输生意事宜，为保证“一日游”生意的顺利经营，共同商谋由苏某某负责打点银海区的关系，陈甲负责打点海城区的关系，林某负责客源、导游等具体运营工作，所得的非法收益由三人共同分配。苏某某与陈甲、林某各自分工负责，相互配合，且利益共享。虽然苏某某对陈甲行贿的具体对象、时间、地点、数额等具体细节不清楚，但在认知层面，苏某某明知陈甲行贿海城区公职人员系按各自事前分工疏通各方关系，以保证“一日游”运输生意的顺利运营，苏某某、林某亦认为没有陈甲“一日游”运输生意根本无法发车；在意志层面，苏某某对陈甲的行贿行为持放任、支持及希望的态度，也即无论陈甲行贿谁、行贿多少，只要保证其经营的“一日游”生意顺利运营并获取非法利益，则不超出被告人苏某某的认知意志范围，仍在其与陈甲事先共谋为赚取非法利益而向相关公职人员行贿的概括性犯意之内，故认定苏某某在主观上具有与陈甲、林某等人共同行贿的故意，客观上伙同陈甲、林某为谋取不正当利益共同实施了行贿行为，被告人苏某某与陈甲、林某构成共同行贿犯罪，对苏某某应以行贿罪共犯论处。

二、苏某某行贿犯罪数额应认定为316万元

根据共同犯罪“部分行为全部责任”的一般性原则，苏某某与陈甲、林某构成共同犯罪，行贿数额应认定为316万元。值得注意的是，苏某某向三名以上司法工作人员行贿，数额认定为131万元(不纳入陈甲行贿数额)还是316万元(纳入陈甲行贿数额)，直接关联苏某某构成“情节严重”还是“情节特别严重”，进一步影响苏某某的量刑档次，需审慎考量。本案属于概括故意型行贿案件，概括型故意经常表现为行为人对同案人行贿的财物价值没有明确认识。对此类案件的犯罪数额，应当考虑行为人的客观行为及其结果，在概括故意的范围内按照主客观统一的原则予以认定。

本案中，主观上，陈甲行贿数额未超出苏某某概括故意的认知范围，苏某

某对陈甲行贿数额有大致了解。首先，苏某某与陈甲事先已有约定，“一日游”运营收入扣除租车、导游、用餐、停车费用后，所得利润对半分取且当日结算，苏某某和陈甲各自从其所得利润中支取部分作为“好处费”给予国家机关工作人员，故苏某某对其和陈甲行贿所需费用从运营所得利润中支取具有概括性认知。此外，苏某某、陈甲、李某对每车收入、利润、分成比例都清楚了解，此前苏某某曾让李某将6万元交予陈甲找海城区政法队伍公职人员疏通关系，又经陈甲分4次行贿给国家机关工作人员共计20万元，苏某某与陈甲互相对对方行贿数额区间有大致了解，二人各自行贿数额近似，可见，苏某某对陈甲行贿数额具有概括性认知，陈甲行贿数额未超出其二人事先共谋为赚取非法利益而向相关公职人员行贿的概括性犯意。

综上，苏某某主观上具有为谋取不正当利益伙同同案人给予国家工作人员财物的概括故意，客观上由其经手行贿国家机关工作人员131万元，另通过陈甲给予国家机关工作人员现金20万元，默许、放任、支持陈甲行贿国家机关工作人员165万元，故认定苏某某伙同同案人行贿316万元符合主客观相一致原则，即使苏某某对同案人行贿的对象、金额等具体细节不明确，但同案人的行为未超出其事前共谋行贿的概括性犯意，仍应认定构成共同行贿犯罪，以保证罪责刑相统一。

编写人：广西壮族自治区北海市海城区人民法院 李新敏

公司实际控制人径自向国家机关工作人员 行贿认定为单位行贿罪

—— 黄某单位行贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2023)桂0203刑初374号刑事判决书

2. 案由：单位行贿罪

【基本案情】

被告人黄某是房地产开发公司和混凝土公司的实际控制人。2012年至2018年，黄某为感谢兰某(前某国家机关工作人员，已判刑)在房地产开发公司房地产项目推进、混凝土公司贷款审批等事项上提供帮助，将位于南宁市的两套房屋、两个车位送给兰某。具体犯罪事实如下：

1. 2014年8月，被告人黄某将位于某小区×栋××号房产及×号车位送给兰某。经鉴定，上述房产及车位共价值427.8133万元。

2. 2016年4月，被告人黄某将位于某小区×栋×号房产及×号车位送给兰某。经鉴定，上述房产及车位共价值159.1387万元。

综上，被告人黄某送给兰某的两套房产及车位共价值586.952万元。

【案件焦点】

被告人黄某作为房地产开发公司、混凝土公司的实际控制人，为帮公司谋

取不正当利益，以个人名义向国家工作人员行贿的行为，应如何定性问题。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：被告人黄某作为房地产开发公司和混凝土公司的实际控制人，为公司谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪。公诉机关指控黄某犯单位行贿罪成立。黄某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。黄某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。黄某行贿的相对人兰某系国家工作人员，兰某在履职和工作过程中对覃某等人存在一定的监督制约关系，兰某利用职务便利为黄某控制的公司的工程建设提供帮助，黄某为表示感谢向兰某行贿，其谋取的利益也归属于单位所有，符合单位行贿罪构成要件，其行为构成单位行贿罪。综上，根据黄某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对黄某适用从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依法判决如下：

一、被告人黄某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币60万元；

二、暂扣于柳州市鱼峰区人民检察院的被告人黄某退出的违法所得人民币200万元，依法予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于：被告人黄某作为房地产开发公司、混凝土公司的实际控制人，为帮公司谋取不正当利益，以个人名义向国家工作人员行贿的行为，应如何定性问题。

第一种观点认为，被告人黄某虽以个人的名义向国家工作人员兰某行贿，

但其最终目的是为其所控制的公司谋取不正当利益，且所获利益归属于黄某所控制的公司，其行为符合单位行贿罪的构成要件，应将其作为单位直接负责的主管人员以单位行贿罪予以指控：

第二种观点认为，被告人黄某行贿犯意系其个人决定，并未经过其所控制的公司集体研究，不属于单位意志，故黄某的行贿应构成行贿罪：

第三种观点认为，被告人黄某系基于兰某利用他的社会关系形成的对其他国家工作人员的影响力，进而通过其他国家工作人员的职务便利为公司谋取不正当利益，应构成对有影响力的人行贿罪。

对此，笔者同意第一种意见。单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。本案中，黄某作为房地产开发公司和混凝土公司的实际控制人，为公司谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其谋取的利益也归属于单位所有，符合单位行贿罪构成要件，其行为构成单位行贿罪。法律规定对“单位行贿罪”实行“双罚制”，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。具体分析如下：

一、行贿意志方面

“单位”作为法律拟制主体，其自身在客观上不可能作出任何行为，其所作的任何行为皆需借由个人之力而付诸实际。笔者认为，是否经过集体研究并不是认定单位意志的唯一条件，单位集体研究决定是形成单位意志的主要形式，但单位的负责人员也可以代表单位形成单位意志。

在认定某一意志是否属于单位意志时，需要结合案件的犯罪目的进行分析，有效处理好“形式”（单位意志形成的程序性要件）与“实质”（单位意志的本质特征）二者的关系。本案中，黄某作为公司的实际控制人，可以代表其公司形成对外行贿的单位意志，其为公司的利益向国家工作人员行贿，其谋利目的是为公司这一整体而非个人，其行贿意志是为单位整体意志所支配的，因此也可以认为，其在该单位共同目标引导下的意志也是代表公司整体所作出的而非代表其个人。

二、行贿名义方面

本案中，被告人黄某将其名下位于南宁市的两套房产以个人名义向兰某行贿，是否意味着黄某的行贿行为构成行贿罪而非单位行贿罪呢？

笔者认为，行贿行为是否以单位名义进行，并不是认定单位行贿罪的必要条件，单位内特定自然人以个人名义但在单位意志支配下的行为也可以是单位行为。从单位犯罪的基本理论来看，若将以单位为名义作为单位犯罪成立的一个必备条件，会将那些秉承了单位意志并为了单位利益而实施的犯罪排除于单位犯罪的范围之外，不仅于法理不合，同时也不利于对该种单位的有效惩治和防范。因此，只要单位成员或其他自然人秉承了单位意志并为了单位的利益实施犯罪，即应视为单位犯罪。本案中，黄某作为涉案公司的实际控制人，其向兰某行贿的目的在于为涉案公司谋取不正当利益，具有单位性，其行贿意志是为该单位意志所支配的，其行贿行为秉承了单位意志并意在为单位谋利，当然应该属于单位犯罪的范畴，故黄某的行为应构成单位行贿罪而非行贿罪。

三、利益归属方面

利益归属的团体性是区分自然人犯罪与单位犯罪的重要区别。利益归属的团体性不仅表现在犯罪意图是为单位谋取利益，而且还表现在最终犯罪所得利益事实上归属于单位而不是由个人据为己有。笔者认为，行贿行为所谋取的利益归个人或行贿的意图是为个人获取一定的利益，则应该按个人行贿来处理；反之，则应该按单位犯罪予以处罚。

本案中，被告人黄某为了感谢兰某在房地产开发公司房地产项目推进、混凝土公司贷款审批等事项上提供的帮助，将位于南宁市的两套房屋、两个车位送给兰某，价值总计586.952万元。其行贿所获取的不正当利益悉数归黄某所控制的两个公司所有。因此，从利益归属的情况来看，其利益归属具有团体性，最终该不正当利益是属于整个单位的，而不是由黄某一个人独吞或是由少数人私分。此外，黄某的犯罪意图也在于为单位谋取利益，而不是为了其个人利益。因此，就此点而言，黄某的行为也应构成单位行贿罪。

四、国家工作人员利用职权谋取不正当利益方面

本案中，被告人黄某向兰某行贿目的是为其控制的公司工程项目推进以及贷款审批等事项上获取帮助。兰某虽系国家机关工作人员，但所获利益并非兰某直接职务范围，是否意味着黄某的行贿行为构成对有影响力的人行贿罪而非单位行贿罪呢？笔者认为，黄某行贿的相对人兰某系国家工作人员，兰某在履职和工作过程中对覃某等人存在一定的监督制约关系，兰某利用职务便利为黄某控制的公司的工程建设提供帮助，黄某向兰某行贿，其谋取的利益也归属于单位所有，符合单位行贿罪构成要件，其行为构成单位行贿罪。

编写人：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 龙梦婷

三、渎职罪

69

村干部滥用职权行为的认定

——朱某某滥用职权、受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省扬州市广陵区人民法院(2020)苏1002刑初465号刑事判决书

2. 案由：滥用职权罪、受贿罪

【基本案情】

2013年至2020年，被告人朱某某利用担任某街道办事处某村党总支副书记、村民委员会主任、党总支书记管理国有土地以及担任某街道办事处城管卫生(数字化)助理、拆迁工作组组长等职务上的便利，多次收受吴某等人所送财物合计价值人民币19.29万元，为上述人员在违规租地、工程款支付、拆迁等方面提供帮助、谋取利益。其中，除公诉机关指控的受贿事实外，公诉机关另指控被告人朱某某构成滥用职权罪，具体犯罪事实如下。

2010年9月，某市国土资源局作出《关于征收集体土地的通知》，将某街道办事处某村32.3公顷的集体土地征归国有。2010年11月，某市拆迁管理办公室发布拆迁公告，由某街道办事处作为拆迁责任单位对某村“城中村改造11

号地块”(以下简称11号地块)进行拆迁。2012年年底,11号地块拆迁结束,交由某村进行管理,该村于2013年在该地块四周修建围墙。

2013年10月,被告人朱某某作为某村党总支书记,以某村村民委员会的名义先后与某渣土运输公司、某建筑安装公司签订《租用合同》,擅自将11号地块中部分土地出租给两公司用于堆放渣土,约定租期均为一年,并收取相应租金。被告人朱某某收受上述公司负责人所送“好处费”共计1.2万元。

被告人朱某某将11号部分地块出租用于倾倒渣土后,未进行监管,在租期届满后,亦未采取有效措施督促上述两家公司按照合同约定清理渣土,恢复土地原状。在11号地块上市前,某村民委员会于2015年7月以招投标方式确定由江苏某工程有限公司对该地块进行土方外运、回填土方和场地平整,累计花费人民币497.06万元,扣减租金、保证金等费用后,实际损失为478.44万元。

【案件焦点】

被告人朱某某滥用职权行为是否构成滥用职权罪。

【法院裁判要旨】

江苏省扬州市广陵区人民法院经审理认为:被告人朱某某作为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,且部分受贿后造成其他严重后果,其行为已构成受贿罪。对于公诉机关指控被告人朱某某因出租11号地块造成某村村民委员会重大损失的事实清楚,唯对被告人朱某某构成滥用职权罪的定性不当。法院认为,根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条和《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定,滥用职权罪的犯罪主体为国家机关工作人员,被告人朱某某系某村党总支书记,不属于国家机关工作人员。本案现有证据亦不能证明被告人朱某某系在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。因此,公诉机关指控被告人朱某某犯滥用职权罪证据不足,不予支持。被告人朱某某收受请托人贿赂,为其谋取利益,致使村集体损失478.44万元,予以从重处罚。被告人朱某某在留置期间主动交

代监察机关尚未掌握的受贿事实，系自首，可从轻处罚。其检举他人犯罪经查证属实，系立功，可从轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人朱某某的辩护人提出被告人朱某某具有自首与立功情节，并积极退出赃款，可从轻处罚的辩护意见，经查具有事实和法律依据，法院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第二款，第六十八条，第九十三条第二款，第三百八十三条第一款一项、第二款、第三款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，作出如下判决：

一、被告人朱某某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15万元；

二、被告人朱某某退出的人民币192880元予以没收，由扣押单位某区监察委员会上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

滥用职权罪是指国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。关于滥用职权罪，《中华人民共和国刑法》第三百九十七条规定犯罪主体为国家机关工作人员。此外，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》规定，在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，或者虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。

本案中，被告人朱某某构成受贿罪较为容易认定，其符合国家工作人员的身份特征，符合受贿罪的犯罪构成，难点在于被告人朱某某是否构成滥用职权罪的主体，即是否属于“国家机关工作人员”。对此，对被告人朱某某是否构成滥用职权罪存在两种不同观点。

第一种观点认为,被告人朱某某构成滥用职权罪的主体。主要理由是11号地块在征收拆迁后上市前应由某街道办负责交付,但在上市前按惯例由属地村负责管理。事实上,被告人朱某某作为属地某村党总支书记,在该地块四周砌建了围墙,需要上市时,亦进行了场地平整,属于在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员,可以成为滥用职权罪的主体。被告人朱某某未向街办领导汇报,亦未经集体讨论,擅自决定将地块出租,事后又未进行追偿挽损,导致公共财产损失478万余元,其行为已构成滥用职权罪。

第二种观点认为,被告人朱某某不能成为滥用职权罪的主体。《中华人民共和国刑法》规定,滥用职权罪的主体为国家机关工作人员。被告人朱某某在管理11号地块的过程中,其本人以及村委会并无国家机关的明确授权,公诉机关亦无相应证据予以证明,不符合《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》中规定的“在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员”,故被告人朱某某不属于国家机关工作人员,不能成为滥用职权罪的主体。

笔者同意第二种观点,理由如下。

一般认为,受国家机关委托代表国家机关行使职权,是指国家机关按照一定程序将某些管理职权委托给非国家机关的组织代为行使,受委托组织对外以国家机关的名义行使国家管理职权,其行为的后果由委托的国家机关承担,对于在受委托行使职权的组织中从事公务的人员,应当视为国家机关工作人员。根据上述要求,可知村干部构成滥用职权罪应符合以下构成要件:一是村委会拥有国家机关的委托,即委托事项有国家机关明确的授权;二是委托的事项必须是政府事务,属于政府行政管理职责范围,而不是村集体事务;三是行为人属于村委会工作人员,在代表国家机关行使职权时有滥用职权行为。因此,对于村干部而言,构成滥用职权罪的前提应是依法或受国家机关委托代表国家机关行使行政管理职权,所从事的公务需与国家机关职权内容紧密联系。

本案中未有证据证明村委会接受国家机关委托。根据《中华人民共和国土地管理法》第五条的规定,国务院自然资源主管部门统一负责全国土地的管理

和监督工作。11号地块收归国有后，管理部门应为区自然资源和规划局。本案中，被告人朱某某所在的村委会管理被拆迁的土地，应当有相关政府部门明确的委托授权，案件在审理过程中，发现并无相应证据能够证明村委会获得授权，村委会砌建围墙、平整土地的行为，仅是自发协助当地政府管理土地的行为，并不能当然证明该村委会接受国家机关委托代表国家机关行使职权。因此，被告人朱某某在担任村干部期间不具备国家机关工作人员的主体资格，不符合滥用职权罪主体身份的要求，其在履职中造成公共财产重大损失的行为，不构成滥用职权罪。

编写人：江苏省扬州市广陵区人民法院 梁田田

70

国家机关工作人员利用职务之便帮助非 国家机关工作人员侵吞国家资产构成滥用职权罪 ——张某某等滥用职权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2022)桂08刑终245号刑事判决书

2. 案由：滥用职权罪

【基本案情】

2014年至2016年，经某区国土厅批复，某县政府组织征收某镇某合社区、某江社区等集体土地作为城市建设用地。2013年8月30日，某县政府批复同意某县城区工业大道延伸段暨城东新区土地收储方案，成立土地收储工作组织领导机构，时任某县住房和城乡建设委员会副主任的被告人张某某与时任某

镇镇长的被告人周某某为该组织机构副组长，负责实施相关土地收储工作。2015年4月，某县政府批复同意的某县城区工业大道延伸段暨城东新区土地收储工作方案对组织机构成员进行了调整，张某某为该组织领导成员，周某某及时任某县政府征地拆迁管理办公室主任的被告人陆某为该组织机构副组长，共同负责组织实施某县城区工业大道延伸段暨城东新区土地收储工作。其中征收某镇某合社区某队坐落于某镇工业大道延伸段的集体土地18.9904亩，作为某小学、某幼儿园建设用地。在开展征地工作期间，被告人杨某1、杨某2、杨某3(三人均为某合社区杨某队村民，杨某1为生产队长，杨某2、杨某3为队干)以帮助政府动员村民配合征地工作为由，向张某某、周某某、陆某提出要求政府额外给予他们9份安置地作为奖励。张某某、周某某、陆某以顺利推进征地工作为由，同意杨某1、杨某2、杨某3提出的要求，超越职权决定奖励杨某1、杨某2、杨某3安置地。张某某、周某某、陆某经与杨某1、杨某2、杨某3共同商量，决定通过伪造承诺书、协议书等征地补偿材料，虚构征用杨某1、杨某2、杨某3各202.5平方米土地的事实，以达到违规奖励杨某1、杨某2、杨某3安置地的目的。后张某某、周某某、陆某利用负责征地、审核、规划、安置等职务之便，在某合社区八某队的国有划拨安置地地段安置了9份国有划拨土地给杨某1、杨某2、杨某3，杨某1、杨某2、杨某3每人得3份，合计607.5平方米。2015年10月，杨某1、杨某2、杨某3在获得安置地规划图后，将9份国有划拨土地使用权分别转让给梁某、许某某等人，并帮助其办理了建设用地规划许可证，获取非法利益共计292.8万元，其中杨某1、杨某2、杨某3分别获利107.8万元、105万元、80万元。案件审理期间，被告人杨某1已退出违法所得2万元至某县法院。

【案件焦点】

国家机关工作人员在履行职务中，为推进工作进行，与非国家机关工作人员共谋，将公共财物交给非国家机关工作人员占有处置，导致公共财物无法追回，在无证据证明国家机关工作人员具有非法占有的故意、非法获利情况之下，国家机关工作人员和非国家机关工作人员构成何罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区平南县人民法院经审理认为：被告人陆某、张某某、周某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人杨某1、杨某2、杨某3，共同虚构政府征收集体土地补偿安置的事实，骗取国有划拨土地使用权，价值数额特别巨大，其行为均已构成贪污罪。在共同犯罪中，陆某、张某某、周某某、杨某1、杨某2、杨某3共同密谋，分工合作，均积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应按照各自所参与的全部犯罪处罚。陆某、张某某、周某某、杨某1、杨某2、杨某3到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，判决：

一、被告人陆某犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；

二、被告人杨某1犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；

三、被告人杨某2犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；

四、被告人杨某3犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；

五、被告人张某某犯贪污罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币60万元；

六、被告人周某某犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60万元；

七、继续追缴被告人杨某1违法所得人民币101.6599万元予以没收，上缴国库；分别追缴被告人杨某2、杨某3各自违法所得人民币103.6599万元予以没收，上缴国库。

宣判后，张某某、陆某、周某某、杨某1、杨某2、杨某3均不服，提出上诉。广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：上诉人张某某、陆某、周某某身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家财产遭受损失，情节特别

严重，三人的行为均已构成滥用职权罪。上诉人杨某1、杨某2、杨某3明知国家机关工作人员滥用职权，仍共同密谋并共同实施伪造征地补偿材料等行为，共同造成国家财产遭受损失且属于情节特别严重，构成滥用职权罪的共犯，依法应以滥用职权罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，六上诉人共同密谋，均积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应按照各自所参与的全部犯罪处罚，张某某、陆某、周某某在共同犯罪中的作用较杨某1、杨某2、杨某3大，量刑时予以区别。六上诉人到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。原判定性错误，导致量刑不当，依法予以纠正。据此，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区平南县人民法院(2022)桂0821刑初243号刑事判决；

二、上诉人(原审被告)张某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年八个月；

三、上诉人(原审被告)周某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年八个月；

四、上诉人(原审被告)陆某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年八个月；

五、上诉人(原审被告)杨某1犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年四个月；

六、上诉人(原审被告)杨某2犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年四个月；

七、上诉人(原审被告)杨某3犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年四个月；

八、对杨某1退出的违法所得人民币2万元，予以没收，上缴国库；责令杨某1退出违法所得人民币105.8万元、责令杨某2退出违法所得人民币105万元、责令杨某3退出违法所得人民币80万元，没收上缴国库。

【法官后语】

本案的争议焦点在于：被告人张某某等六人行为的定性问题。法院在审理过程中，对六被告人构成何种罪名，形成四种不同意见：第一种意见认为，张某某等3名国家机关工作人员构成滥用职权罪，杨某1等三名非国家机关工作人员构成诈骗罪。理由是国家机关工作人员没有非法占有的意思表示，不能认定贪污罪，但国家机关工作人员明知村民不符合国家补偿安置条件，仍帮助或不认真履行职责，使国家资产被骗取的，构成滥用职权罪。非国家机关工作人员以欺骗手段骗取公共财物，构成诈骗罪；第二种意见认为，张某某等六人均构成贪污罪，理由是国家机关工作人员利用手中权力，通过他人非法占有国家财物，均构成贪污罪；第三种意见认为，张某某等六人均构成诈骗罪。理由是国家机关工作人员帮助他人骗取国家资产，不管是否分赃，均构成滥用职权犯罪与诈骗罪的想象竞合，从一重罪即诈骗罪处罚；第四种意见认为，张某某等六人均构成滥用职权罪。理由是国家机关工作人员出于工作需要，利用手中权力将公共财物给予他人，导致损失，属于滥用职权罪范畴，非国家机关工作人员属于共犯。

综合本案的情况，笔者同意第四种意见，认为张某某、陆某、周某某身为国家机关工作人员，超越职权，违法处置国家划拨土地，造成国家财产损失，情节特别严重，其行为均构成滥用职权罪。杨某1、杨某2、杨某3与国家机关工作人员张某某、陆某、周某某共谋，利用国家机关工作人员违法处置国家划拨土地归三人所有，构成滥用职权罪的共犯。具体分析如下：因张某某、陆某、周某某三人均未占有公共财物，也未与杨某1、杨某2、杨某3约定事后分赃，张某某、陆某、周某某主观上没有非法占有公共财物目的，即无贪利，故不符合贪污罪中具有非法占有的主观故意，不构成贪污罪。但本案中，张某某、陆某、周某某超越职权，违规给不符合征拆安置的人员杨某1、杨某2、杨某3安置回建安置地，且造成国家财产损失，情节特别严重，符合滥用职权罪构成要件，构成滥用职权罪。对村民杨某1、杨某2、杨某3的定性，虽然《中华人民共和国刑法》及相关司法解释没有明确非国家工作人员伙同犯罪的以共犯处

理，但《中华人民共和国刑法》总则关于共同犯罪的规定具有整体指导性作用，且《全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职罪主体适用问题的解释》规定：“在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员……在代表国家机关行使职权时，有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。”该解释对国家机关工作人员作出了扩大解释，即排除了仅有国家机关工作人员才构成滥用职权罪的说法。本案中，张某某、陆某、周某某三名国家机关工作人员的行为，具有不可替代性和非转让性，是杨某1、杨某2、杨某3三名非身份者不可能实施的行为，如果没有三名国家机关工作人员的行为，三名非身份者的行为不仅无法实施，而且也失去实施的必要性，也正是三名国家机关工作人员的教唆及利用职务之便才能得逞，故本案三名非身份者的行为实际上是附属于三名国家机关工作人员的行为，行为性质应当以三名国家机关工作人员行为的性质来确定，即对三名非身份者以滥用职权罪定罪处罚。

编写人：广西壮族自治区贵港市中级人民法院 卢阳德 郑雪霞



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 刑事案例. 四/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编. —北京: 中国法治出版社, 2025. 4. — ISBN 978-7-5216-5103-4

LD920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025MV7564号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 白天园

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 刑事案例. 四

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLIXINGSHI ANLISI

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年4月第1版

印张/20 字数/240千

2025年4月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-5103-4

定价: 79.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网 址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141792

印务部电话：010-63141606